

刑法
No88

共通問題 R7-6

(配点：3)

月 日

月 日

正当防衛に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 正当防衛は、不正の侵害に対して成立するから、正当防衛が成立する行為に対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。
2. 不正の行為により自ら侵害を招き、これに対して反撃した場合、正当防衛が成立することはない。
3. 急迫不正の侵害がないのにあると誤信し、自己の権利を防衛するため、加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。
4. 相手方による侵害を予期している者が、自己の権利を防衛するため、同侵害が間近に押し迫っていないのに相手方に加害行為をした場合、正当防衛が成立することはない。
5. 相手方による侵害に対して反撃した者が、その侵害から予想された被害よりも大きい被害を相手方に与えた場合、正当防衛が成立することはない。

No88	正当防衛	正答率
共通R7-6	正 解 2、5 (順不同)	88%

1 正しい

正当防衛は、「不正」な侵害に対してのみ可能である(36条1項)。「不正」の意義につき、違法であることを意味するとされている(大判昭8.9.27)。正当防衛行為は、違法性が阻却されるため、「不正」な侵害ではない。したがって、正当防衛に対する行為に対して反撃しても、正当防衛は成立することはない。

2 誤っている

最決平20.5.20(百選I26事件)は、相手方の攻撃が「被告人の暴行に触発された、その直後における近接した場所での一連、一体の事態ということができ、被告人は不正の行為により自ら侵害を招いたものといえる」場合について、相手方の「攻撃が被告人の前記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては」との留保を付した上で、正当防衛の成立を否定した原審の判断を正当としており、相手方による侵害を自ら招いた者が反撃行為をした場合に正当防衛が成立する余地を否定しているわけではない。

3 正しい

急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して、それに対し反撃行為を行った場合が誤想防衛の典型であり、誤信した侵害が実際にあるとした場合に許容される範囲の行為を行ったときには、故意は阻却され、誤信したことについて過失があれば過失犯が成立する。いずれにしても、存在しない急迫不正の侵害が存在することとなるわけではないから、正当防衛が成立することはない。

4 正しい

最判昭46.11.16。「急迫」(36条1項)とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることをいう。そうすると、相手方による侵害が間近に押し迫っていない場合、侵害の「急迫」性の要件を満たさない。したがって、侵害が間近に押し迫っていないのにした加害行為には、正当防衛が成立する余地はない。

5 誤っている

最判昭44.12.4は、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味するのであって、反撃行為が右の限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではない」としている。正当防衛は、「不正対正」の関係である以上、「正対正」の関係である緊急避難と異なり、厳格な法益の均衡は要求されない。したがって、正当防衛の他の要件を満たせば、正当防衛が成立する。

以上により、誤っている記述は2と5であり、したがって、正解は肢2と肢5(順不同)となる。